

1500406-38.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

Processo Digital 1500406-38.2021.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500406-38.2021.8.26.0542

Controle: 2021/000258

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

MATHEUS SANTANA RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

MATHEUS SANTANA RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, em 14 de fevereiro de 2021, na Rua Teotônio Vilela, 37, Santa Maria, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, trazia consigo: 34 invólucros plásticos contendo 3,3g de crack, 86 invólucros plásticos contendo 63,8g de cocaína e 79 invólucros plásticos contendo 41g de maconha, todas substâncias entorpecentes, capazes de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina, pelo local dos fatos, quando se depararam com Matheus, que carregava algo em mãos.

Diante da presença da guarnição Matheus tentou se evadir, ensejando sua abordagem.

Em revista pessoal, os guardas civis encontraram com Matheus um necessaire marrom contendo o estupefaciente. Também foi apreendida, junta ao corpo de Matheus, uma pequena bolsa, contendo R\$ 60,00.

Informalmente, Matheus afirmou que guardas municipais que traficava ali.

A denúncia foi ofertada e devidamente notificado Matheus (fls. 111). Sobreveio a defesa preliminar (fls. 114/128) e, não havendo causas de sumária absolvição, a

denúncia foi recebida em 23 de março de 2021 (fls. 134/136). Matheus foi citado (fls. 157).

Durante a instrução processual criminal foram ouvidas testemunhas (fls. 187/188). Deixou-se de prosseguir com o interrogatório do acusado, sendo decretada sua revelia (fls. 189).

Encerrada a instrutória, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 189).

Em sede de memoriais escritos, o Dr. Promotor de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Matheus nos termos exatos da denúncia (fls. 192/196).

A Defesa, por seu turno, pugnou, preliminarmente, pela nulidade em razão de ilicitude da prova obtida pela Guarda Municipal e, no mérito, pela absolvição, conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pela desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06 ou pela aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (fls. 136/154).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Inicialmente, afasto a aventada ilicitude da prova. A Guarda Municipal não se afastou dos limites de sua competência ao realizar a abordagem de Matheus. Isto porque ele, ao perceber a presença da guarnição, tentou se evadir, sendo abordado. A Guarda Municipal agiu, assim, sob a égide do artigo 301 e artigo 303, ambos do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva se consubstancia em auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 5/7), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9) e laudo pericial de constatação (fls. 20/23), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 187/188).

Perante a D. Autoridade de Polícia Judiciária, Matheus se reservou no direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 4). Em Juízo teve sua revelia decretada (fls. 189).

A testemunha Guarda Municipal Paulo Anderson declinou que em patrulhamento na Rua Teotônio Vilela visualizaram o acusado, que portava duas pequenas bolsas nas mãos. Quando ele avistou a viatura, assustou-se e tentou se evadir. Alcançaram ele e o detiveram. Perguntaram o que havia na bolsa que porque ele correu. Ele confessou o tráfico e disse que havia drogas na bolsa. Em uma bolsa foi localizada a droga e na outra valor em dinheiro.

Não fizeram campana no local. A ocorrência foi entre meio-dia ou 13h. O local é uma comunidade e havia bastante gente. Não havia pessoas próximas dele. Tinha pessoas olhando. Ele não se desvencilhou das bolsas. Foi o declarante que fez a revista pessoal no acusado. Eram pequenas bolsas, tipo pochete. Não soube informar se são tipos de bolsa para segurar na cintura ou ombro. Não se recordou o que foi respondido pelo acusado, mas sempre é perguntado, depois da abordagem, se tem passagem (fls. 187).

A testemunha Guarda Municipal Celso Aparecido relatou que, em patrulhamento na via, avistaram o acusado que tentou se evadir, mas foi alcançado logo na frente. Seu parceiro fez a revista e apreendeu duas bolsas com ele, nas quais havia droga e dinheiro. Ele informou que estava na mercancia das drogas e que o dinheiro era oriundo do tráfico.

Não fizeram observação do acusado antes da abordagem. Não se recordou se havia pessoas ao lado do acusado ou não. As drogas estavam em bolsas que estavam junto ao corpo do acusado. A cor era escura (fls. 188).

Os testemunhos dos guardas civis demonstram a veracidade dos fatos, até porque responderam às indagações formuladas, apresentando as mesmas circunstâncias, no aspecto principal quanto secundário, quer na fase extrajudicial como em Juízo.

É cediço que o testemunho policial não é afetado, positiva ou negativamente, pela função que exerce. A condição funcional não confere ao seu testemunho maior força persuasória e nem o inquina de suspeição. O valor probante de sua versão é aferido pelo mérito e de acordo com o grau de confiabilidade segundo a harmonia das provas coligidas aos autos. Neste sentido, vasta é a jurisprudência proclamada pela

suficiência, se coesos os testemunhos policiais, para embasar o édito condenatório. "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial" (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha afim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V.U.).

As provas são uníssonas e coesas quanto à responsabilidade criminal de Matheus. Ele foi abordado, após tentar fugir, diante da aproximação da guarnição. Abordado, com ele havia duas bolsinhas, nas quais havia entorpecente e dinheiro. Informalmente, Matheus confirmou que estava traficando e que o numerário localizado era oriundo da traficância.

Para caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes dever-se-á atender à natureza e a quantidade da substância entorpecente, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Seguindo essas variantes houve plena demonstração do animus de traficar, sendo robusto o material cognitivo.

Ora, os elementos citados são suficientes e indicam que o material tóxico apreendido se destinava ao comércio ilícito.

Matheus foi denunciado por trazer consigo substância entorpecente cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários, tais como a confissão extrajudicial, a quantidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes dos agentes, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciem a atividade delituosa" (TJRJ - ApCrim 5.492 in Direito Concreto, v. 5, p. 191).

"Desimporta se o agente não chegou a vender o tóxico, pois trazer consigo, já é delito consumado, segundo uma das normas múltiplas que contém o art. 12 da lei respectiva" (TJRS - AC 68.305.178-3 - Rel. Milton dos Santos Martins - RJTJRS 107/59).

Com esta prova a respeito da finalidade de entrega do entorpecente a consumo de terceiros não há que se cogitar da desclassificação para o delito preconizado no artigo 28, da Lei 11.343/06. Anote-se que a condição de usuário não exclui a traficância.

Conclui-se, pois, pela procedência da ação penal e consequente condenação de Matheus Santana Ribeiro por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não agiu com intensidade dolosa incomum para os delitos da espécie a justificar a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do autorizado pelo artigo 59, do Código Penal.

É tecnicamente primário.

É pertinente a redução prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.887.511-SP, que fixou diretrizes acerca da consideração da quantidade e variedade de entorpecentes na dosimetria da pena.

"PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elege-se dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminoso ou à integração a organização criminoso. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença" (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Assim, tratando-se de agente primário, a redução deve se dar em seu grau máximo, ou seja, 2/3, conforme o preconizado pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Considerando os parâmetros acima e os demais critérios preconizados pelo artigo 59, do Código Penal, fixo, a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na base. Não há atenuantes ou agravantes. Reconhecida a aplicação do § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, calculados na base. Não há outras causas de diminuição ou de aumento.

À míngua de outras causas legais de alteração torno esta pena definitiva.

Em face do disposto no artigo 33, alínea c, do Código Penal e artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixo o regime inicial aberto. Por força da Resolução 5/2012 do

Senado Federal, não havendo óbice, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo nacional, à A.A.C.D./Osasco-SP, e prestação de serviços à comunidade por igual prazo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO MATHEUS SANTANA RIBEIRO, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo nacional, à A.A.C.D./Osasco-SP, e prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O sentenciado respondeu a este processo-crime em liberdade e assim poderá recorrer, observando-se a reprimenda aplicada.

Nos termos do artigo 60, c.c. o artigo 63, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 125, do Código Penal, atendido ao requisito do artigo 126, do Código Penal, e a teor do artigo 127, do Código Penal, decreto o perdimento do numerário apreendido, dada sua origem ilícita.

No mais, autorizo a destruição do entorpecente nos termos regimentais, bem como do aparelho telefone celular.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P. I.C.

Osasco, 11 de julho de 2022.